

1501831-49.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... de precisão, embalagens etc), dinheiro ou anotações de tráfico em sua residência. Além disso, as provas produzidas demonstraram que o réu Paulo não era proprietário das drogas, tendo agido como intermediador da negociação. Em caso similar:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial que visa o afastamento do tráfico privilegiado, a fixação do regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501831-49.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501831-49.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2337068/2021 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 21893197 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2017/21/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CÉSAR RODRIGUES JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

PAULO CÉSAR RODRIGUES JÚNIOR e LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 18h20, na Rua XV de Novembro, nesta Cidade e Comarca de José Bonifácio, PAULO CÉSAR RODRIGUES JÚNIOR e LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, qualificados respectivamente às fls. 04 e 203, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas e, nesta qualidade, transportavam e tinham em depósito,

para fins de tráfico, 9,57kg (nove quilogramas, quinhentos e setenta gramas) de tetrahydrocannabinol - THC, divididos em 11 tijolos e 09 porções, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão da droga de fls. 13/14, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de substância entorpecente de fls. 16/21 e Laudo Pericial Definitivo de fls. 109/111). Apurou-se, que os denunciados se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas na Cidade de José Bonifácio.

Assim, no dia e local dos fatos, policiais militares durante patrulhamento de rotina pela área central de José Bonifácio, depararam-se com um veículo VW/Voyage, cor verde, de placa BJI-6G56, tendo os seus ocupantes ao perceberem aproximação da viatura, demonstrado certo nervosismo, de forma que decidiram pelo acompanhamento na tentativa da abordagem, quando, de inopino, um dos ocupantes, o passageiro Paulo César, ora denunciado, repentinamente, abriu a porta e pulou do automóvel com um pacote em mãos, enquanto o condutor do Voyage, o denunciado Luís Henrique, continuou a fuga e não foi capturado.

De tal forma, efetuaram a abordagem do denunciado Paulo César, e com ele foram apreendidos dez (10) tijolos de erva semelhante a maconha e mais meio tijolo da mesma substância e a quantia de cinquenta e quatro reais em dinheiro.

Indagado se havia mais entorpecentes em seu poder, o denunciado Paulo César confirmou que havia mais algumas porções na sua residência, para onde se dirigiram e procederam a busca, localizando mais 09 porções de erva semelhante a maconha, que se estavam dentro do quarto, em uma tábua debaixo da televisão.

O denunciado Paulo César foi levado para atendimento médico na Santa Casa, em razão dos ferimentos quando pulou do automóvel (na orelha, no rosto, no braço e na perna esquerda).

Inquirido informalmente, Paulo César confessou que tinha o entorpecente para venda, pelo valor de R\$ 10,00 cada porção e que ganharia a quantia de R\$ 200,00 por cada tijolo.

Diante da D. Autoridade Policial, confessou a traficância.

Em prosseguimento às investigações, o denunciado Luís Henrique foi identificado pelos policiais, e perante a D. Autoridade Policial confessou que foi ele quem conduziu o veículo placas BJI 6G56 no dia dos fatos, negando a traficância.

Todavia, o denunciado foi preso em flagrante posteriormente pela prática de tráfico de entorpecente (fls. 196/201).

Auto de Exibição e Apreensão da droga de fls. 13/14, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de substância entorpecente de fls. 16/21 e Laudo Pericial Definitivo de fls. 109/111.

As circunstâncias da apreensão, bem como a grande quantidade da droga autorizam a capitulação da conduta como tráfico.

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls. 288/290).

Citados (fls. 186; 247), e apresentaram resposta à acusação (fls. 222/244; 286/287).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que as testemunhas foram ouvidas, e interrogados os acusados ao final.

O Ministério Público requereu a procedência do pedido, nos termos da denúncia.

As Defesas requereram a improcedência da denúncia, com a absolvição dos réus.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, quanto ao Tema 1185, observa-se que, embora reconhecida a existência de repercussão geral, a questão permanece pendente de julgamento. No entanto, ainda que assim não o fosse, não há que se falar em nulidade do processo. Com efeito, ouvido em juízo, o policial declarou que, ao réu, foi garantido o direito ao silêncio e que ele colaborou espontaneamente. Destaco que a palavra do agente público se reveste de credibilidade e fé pública, não havendo motivos para deperece-la nessa oportunidade.

No mesmo sentido, consoante se verifica em depoimento de fls. 04/05, o réu foi

expressamente advertido quando ao direito ao silêncio pela Autoridade Policial. Além disso, eventual nulidade, se existente, dependeria da prova do prejuízo concreto ao acusado, o que não ocorreu. Soma-se a isso que eventual nulidade do inquérito policial não produz reflexos na fase judicial. Em caso semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória. Preliminares. Alegação de violação ao art. 212 em razão de o magistrado ter realizado a inquirição das testemunhas antes das perguntas das partes. Nulidade relativa. Prejuízo não demonstrado. Alegada ilegalidade na busca pessoal. Rejeição. Fundada suspeita da prática de crime evidenciada. Alegação de ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio quando da abordagem policial. Nulidade relativa. Constrangimento não evidenciado. Prejuízo não comprovado. Irregularidades na fase policial, sem reflexo na fase judicial. Preliminares rejeitadas. Mérito. Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório. Absolvição e desclassificação incabíveis. Dosimetria. Imperioso o afastamento da agravante da calamidade. Concessão do redutor na fração máxima, uma vez que preenchidos os requisitos legais. Cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Regime prisional alterado para o aberto. Novel orientação do Pretório Excelso acerca da não hediondez do "tráfico privilegiado", que já era seguida por esta Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, e agora está consolidada pela Lei nº 13.964/2019, a permitir a adoção de regime inicial mais brando para o desconto da reprimenda corporal, de todo mais adequado a esse entendimento, bem como suficiente para a repressão do delito e ressocialização do agente. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500181-88.2021.8.26.0551; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também caminha no mesmo sentido, no julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO APONTADO. 2. ABORDAGEM EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECLARAÇÕES PRÉVIAS E ESPONTÂNEAS DO CORRÉU. INTERVENÇÃO ATIVA. VISTORIA EM CARRO COM 90KG DE MACONHA. DESCOBERTA INEVITÁVEL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO. VISTORIA REALIZADA. CHAMADAS EFETUADAS E RECEBIDAS. FOTOS DOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. PROVA ILÍCITA. ART. 157 DO CPP. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE. 1. O STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 04/05/2016). No caso em tela, o impetrante nem sequer apontou em que consistiria eventual prejuízo. Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada ao recorrente e aos corréus, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos. 2. Os policiais militares realizavam fiscalização de rotina na rodovia, razão por que a realização de conferência de documentos e vistoria de veículos, bem como a entrevista dos motoristas e passageiros que ali transitavam constituíam condutas elementares. Neste sentido, revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas. Ademais, o corréu, após perceber que seu veículo seria vistoriado, "admitiu informalmente aos policiais que transportava substância entorpecente no veículo". Portanto, diante da descoberta iminente e inevitável de 90kg de maconha escondidos no automóvel, o corréu decidiu falar espontaneamente, situação que não pode ser

considerada como violadora do direito de não produzir provas contra si mesmo. De fato, "a opção pela intervenção ativa implica abdicação do direito a manter-se calado e das consequências da falta de informação oportuna a respeito" (HC 78708, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 09/03/1999). (...) (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 25/10/2016, DJe 07/11/2016) (negritei).

Portanto, não comprovada qualquer nulidade. Afasto a preliminar suscitada. O processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há nulidades ou vícios a serem sanados. Os réus foram representados por Defensores e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas.

Assim, passo à análise do mérito.

A pretensão penal punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE, sendo as provas dos autos suficientes para condenar os réus apenas pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade deste delito (artigo 33, da Lei 11.343/06) evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), termos de depoimentos (fls. 02/03), termos de interrogatórios (fls. 04/05; 203/205), notas de culpa (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudos periciais (fls. 16/21; 109/111), relatório final (fls. 115/116), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Márcio da Silva Tome (testemunha comum) disse que apenas Paulo César foi abordado. Estava em patrulhamento em José Bonifácio. Viram um carro e eles, ao verem a viatura, começaram a se evadir. Eles correram muito. Em um dado momento, Paulo pulou com uma sacola na mão. Ele sofreu algumas lesões e foi abordado. A placa do carro foi irradiada, para tentar localizar o veículo Voyage. Paulo César disse que fez contato com uma pessoa de Rio Preto, que encomendou 10kg de maconha. Ele sabia que Luís Henrique tinha a droga. Ele fez contato com Luís e foram fazer a entrega. A droga era de Luís e ele ganharia R\$ 200,00 por cada kg (tijolo) que vendesse. Ele não soube informar quem era a pessoa. Disse apenas que estava em um Voyage prata e com dinheiro para a compra. Ele disse que tinha mais maconha em casa e localizaram 9 porções. Ele foi encaminhado ao pronto socorro. Com ele, foi localizado em um aparelho celular e R\$ 54,00. Paulo iria receber uma quantia pela venda da droga. Ele estava fazendo intermediação, porque a droga seria de Luís Henrique. Durante o acompanhamento, do ângulo que estava, só viram que ele saiu do carro. Questionado, ele falou que pulou para tentar se desfazer da droga. Depois, ele falou que Luís Henrique falou para ele pular, porque Luís já tinha antecedentes. Ele deu duas versões, mas nenhuma delas foi que ele foi empurrado do carro. Paulo não era conhecido dos meios policiais. O depoente vai muito pouco em José Bonifácio. Está acrescentando o que foi dito no dia. Tem um vídeo gravado com Paulo, falando exatamente o que foi falado aqui. Pode ser que não tenha se recordado na hora sobre as informações. Disse a ele que ele poderia permanecer calado e que ele não precisava responder às perguntas. Inclusive, ele falou que tinha drogas na casa e que a família não tinha qualquer relação com a droga. Começou a acompanhar o carro. O carro não era conhecido, nem os ocupantes. Não comentou na delegacia que Luís era conhecido dos meios policiais. Os réus iniciaram fuga quando viram a viatura, não pararam em sinais de pare, colocando em risco a vida de outras pessoas. Não tem informações do réu Paulo de que ele foi empurrado. Apenas a viatura do depoente estava acompanhando. Paulo indicou, aproximadamente, o bairro em que Luís morava. Não localizaram a casa. Ele indicou o nome da pessoa e o local aproximado, mas a localização do réu é da parte de investigação da Polícia Civil. Paulo disse que pegou a droga de Luís Henrique para fazer a entrega da droga para um adquirente. Ele não explicou como ele chegou ao local. Não tiveram contato com Luís. Não sabiam quem era. A droga estava embalada em tijolos, 10 grandes e um menor, em plástico verde. Paulo não mencionou de onde conhecia Luís e se eram amigos. Bruno Henrique Ferreira Dias (testemunha comum) disse que, no dia, estavam em

patrulhamento pela cidade. Viram um veículo querendo estacionar. Ao se aproximar, eles começaram a se evadir. Fizeram um acompanhamento e viram um indivíduo saltando do veículo, com uma sacola. Ele rolou pelo chão. Abordaram-no e era Paulo. Na queda, Paulo machucou a orelha. Verificaram que tinha droga na sacola e 54 reais. Paulo disse que Luís Henrique era o motorista do Voyage. No dia, não conseguiram abordar Luís Henrique. Não se recorda se Paulo falou se foi empurrado ou se pulou do carro. Paulo indicou o nome de Luís e o bairro, mas sem outros elementos que permitissem encontrá-lo. Ele disse que estava intermediando a negociação da droga e iria ganhar 200 reais por kg de drogas vendido. Não se recorda de ter feito outra abordagem em Paulo. Sobre Luís Henrique, não teve informações sobre ele posteriormente. Paulo informou que vendia droga e parte da droga foi localizada em uma prateleira, debaixo da TV. Não se recorda se as vias que eles passaram possuía semáforos, mas se recorda que eles não respeitaram sinais de pare. No dia, Paulo foi solícito. Ele respondeu a tudo que foi perguntado e informou a residência, onde estava a droga restante, informou dados do condutor. Ele permitiu a gravação. Não se recorda, mas acredita que os fatos ocorreram perto de uma praça. O depoente não conhecia o veículo. Não se recorda se Paulo disse ter sido empurrado do veículo. Não se recorda quantas viaturas tinham no local. Lembra-se que informaram por rádio que o veículo tinha se evadido. Não se recorda de ter abordado Luís Henrique. Paulo disse que a droga seria de Luís Henrique e ele faria a intermediação da venda, com o comprador. Não se lembra se Paulo informou de onde conhecia Luís Henrique. Paulo César Rodrigues (informante- pai do réu Paulo) disse que é pai de Paulo. Ele é um excelente filho e uma excelente pessoa. O filho é usuário de maconha. Lutaram por 4 anos para tirar o vício. Ele trabalhava com o depoente de servente. Depois, entrou na usina. Paulo trancou a faculdade para ajudá-lo. Paulo ia ao trabalho todos os dias. Na hora de folga, os amigos do Paulo iam até a sua casa para conversar. Não existiam pessoas que iam pegar algo e saíam. Paulo nunca teve envolvimento com venda de drogas. Paulo tinha vários amigos. Luís era conhecido de vista, do bairro, morava perto da casa. Paulo não bebe ou arruma confusão. Nunca perdeu dias de trabalho. Sabia onde Luís morava, porque fez serviço de pedreiro para a mãe dele. Luís Henrique não frequentava a casa do depoente. Na casa de Luís Henrique, via muito movimento de venda de drogas. Nunca teve conversa com o filho, porque eles não tinham amizade. No dia da prisão, estava viajando. Não estava na cidade.

Vinicius Monteiro Alves (informante- amigo íntimo de Paulo) disse que conhece Paulo desde a infância, pois cresceram juntos. Nada sabe sobre algo que desabone a conduta de Paulo. Morou na casa com Paulo. Paulo sempre trabalhou. Recentemente, ele estava na usina. Paulo faz uso de drogas. Nunca o viu entregando drogas para ninguém. Não sabe de nada que o desabone. Conhece Luís Henrique, mas não tem amizade com ele. Acredita que Paulo tenha amizade com Luís Henrique. Nunca viu os dois juntos. Sabe onde era a residência de Luís Henrique. Era no bairro, perto da casa de Paulo. Luís Henrique tem passagens por drogas. Isso era de conhecimento comum. Estava a cidade, mas não acompanhou as buscas, embora estivesse na cidade. Deivid de Carvalho Sarro (informante-amigo íntimo de Paulo) disse que conhece Paulo desde 3 anos de idade, pois cresceram juntos. Paulo sempre foi tranquilo. Ele trabalha com o pai e, recentemente, estava na usina. Paulo fuma maconha, mas não é direto. O vício não o atrapalha, pois ele trabalhava todos os dias. Ele nunca deu prejuízo para ninguém. Quando trabalhava na Prefeitura, frequentava a casa de Paulo todos os dias. Nunca viu Paulo entregando drogas. Não mora no mesmo bairro. Não conhece Luís Henrique. Não sabe se Paulo e Luís Henrique têm amizade. Não presenciou o dia da prisão, mas tomou conhecimento pela mãe dele.

Wilson Rogério da Silva (informante-primo do réu Luís) disse que é vidraceiro e tem demanda alta. Luís é primo do depoente e sempre o chama para ajudá-los, pagando o dia dele. Pagava 70/75 reais o dia de trabalho. O pagamento é para carregar peso. O horário é de 7h até 17:30h. Utilizava a ajuda dele com frequência. Ele nunca deu problema, sempre trabalhou corretamente. Ele trabalhava quase todos os dias da semana. Não consegue lembrar se ele estava trabalhando no dia dos fatos. Não tinha conhecimento do envolvimento do primo com drogas. Não tem conhecimento sobre os fatos. Já viu Paulo com Luís Henrique. Não sabe se eles eram amigos. Eles moravam

perto, quase no mesmo bairro.

Paulo César Rodrigues Junior (réu) disse que tem 29 anos. Estava trabalhando na usina Morena, passando veneno na cana. Não estava estudando, pois tinha trancado a faculdade. Tinha carteira assinada e ganhava 1750 reais por mês. É solteiro. Não tem filhos. Nunca respondeu a processo antes. Só tem passagem de usuário. Disse que, na data, pegou um mototáxi e encontrou Luís na praça. Estava conversando com ele e ele foi ao encontro de um indivíduo de um Voyage prata. Na volta, entraram no carro dele. Ele disse que não tinha localizado o indivíduo. Estavam parados na praça e ele viu a viatura. Então, começou a empreender fuga do carro. Desceram a rua da pracinha e tomou conhecimento da droga no carro. Em um dado local, ele pediu para o depoente dispensar a droga. Abriu a porta para dispensar a droga e sentiu um empurrão. Caiu fora do carro com a droga. Os policiais o abordaram e deram um mata leão, quase desmaiando-o. Eles fizeram as perguntas. Disse que a droga era de Luís Henrique e que não tinha conhecimento da droga. Tinha 9 porções de maconha, mas era para consumo. Consumia maconha há 15 anos. Foi levado ao hospital. Foi encontrar Luís Henrique porque devia para ele e iria pagar a droga que tinha comprado. Caminhou com ele para encontrar uma pessoa. Mas, quando ele voltou para o carro, Luís não viu mais essa pessoa. Ele encontrou a pessoa para negociar a droga. Presenciou os fatos. Não participou da negociação de drogas. Não sabia a quantidade de drogas que ele tinha dentro do carro e iria pegar uma carona. Não sabia que ele já estava com a droga. Voltaram para o carro e ia pegar a carona para ir para casa. Quando ele viu a viatura, ele fugiu. Ia jogar a droga do carro, porque ele pediu. Ele era conhecido, não amigo do depoente. A droga estava trás do banco. Ele colocou a droga no colo e pediu para dispensar a droga. Ficou com medo dos dois serem presos e, por isso, resolveu tentar jogar a droga fora. Não falou para os policiais que estava intermediando a negociação de drogas. Contou a versão que está contando agora. Não conhecia os policiais. Não teve problema com a polícia. Não sabe dizer o porquê os policiais estão contando uma versão diferente. Na delegacia, contou a mesma versão. Não falou que a droga era para vender, nem que intermediou nada. Falou isso na delegacia, que tinha feito a intermediação da droga. Conversou com indivíduo e só passou o contato dele com Luís. Não sabe o que eles combinaram. Foi para pagá-lo e, por coincidência, ele estava negociando a droga. Não falou na delegacia que tinha se envolvido com o tráfico de drogas, nem que iria receber pela negociação. É apenas usuário. Não entrou com uma sacola com drogas, dentro do carro. Uma terceira pessoa queria comprar drogas e indicou o contato de Luís Henrique. Quando essa pessoa foi comprar de Luís Henrique, por coincidência, estava presente no local. Foi à pracinha para pagar a droga que tinha comprado. Quando Luís começou a fugir, ele puxou a droga de trás do banco do passageiro, colocou no seu colo e falou para jogar. Comprava drogas de Luís Henrique. Nunca foi entregar drogas com Luís. Nunca esteve na casa de Luís para embalar drogas, nem o viu embalando drogas. Encontrou Luís na pracinha. Ficou 10 minutos na praça com Luís. Luís não iria pagar nada para ajudá-lo. Não conhece a terceira pessoa. Somente a viu quando Luís o chamou para vê-lo perto do posto. Não sabe quanto custa 1kg de maconha, nem quanto Luís ganharia. Está arrependido de estar no local. Está livre dos vícios do cigarro e da maconha. Reconciliou-se com Deus.

Luís Henrique Rodrigues da Silva (réu) disse que tem 26 anos. É amasiado. Tem um filho de 01 ano e 10 meses. Antes da prisão, trabalhava com o primo, de ajudante de vidraceiro. Já respondeu a outros processos. Disse que, no dia, tinha saído para abastecer o carro. Encontrou Paulo na pracinha, que pediu a carona. Ele pediu carona até a rodoviária. Ele entrou no carro e, quando estavam saindo, viram o carro da polícia. Ele pediu para correr, que iria pular do carro. Andou uns dois quarteirões e ele pulou do carro. Paulo era conhecido. Ele entrou no carro com uma sacola. Não sabia o que tinha. Não saiu correndo, continuou na mesma velocidade. Estava em velocidade normal. Ele pulou do carro. Fechou a porta e foi embora. Não viu a polícia pedindo para parar. Achou estranho ele pular do carro. Quis sair da situação. Não sabia de drogas, nem tinha nada de ilícito no carro. Trafegou normalmente. Acha que os policiais falaram isso, porque andou e não viu que eles pediram para parar. Não conhecia os dois policiais. Não tinha problema com os policiais ouvidos. Não sabe dizer o porquê Paulo contou essa história. Era apenas

conhecido de Paulo. Nunca vendeu drogas para Paulo. Não tem qualquer envolvimento com drogas, seja pela venda, seja pelo uso. Não procurou a polícia, porque caberia a polícia vir até ele para pegar seu depoimento. Não tinha ciência do que tinha ocorrido. Não chegou qualquer intimação ao depoente e, quando intimado, prestou seu depoimento. O carro é do depoente. O depoente estava dirigindo. Fugiu, porque ficou assustado, já que Paulo falou todo apavorado. Paulo é que quis pular do carro. Paulo falou que iria pular do carro e não tinha nada a ver com a situação. Abasteceu no posto gasolina BR. O telefone do depoente está apreendido. Não sabe se já tem perícia. Não ligou para a namorada dizendo que tinha "moiado". Assim, finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório parcial apenas quanto ao delito de tráfico.

Perante a Autoridade Policial, o réu Paulo César disse que: "Quando passamos a andar com o veículo, fomos inesperadamente abordados por uma viatura policial do BAEP. LUIS passou a fugir em alta velocidade. LUIS mandou eu jogar a droga que estava atrás do banco dele, pela janela. Somente naquele momento tomei conhecimento da quantidade de droga que LUIS iria vender. Quando eu abri a porta para jogar a droga para fora, LUIS me empurrou com os pés nas minhas costas. Eu caí no asfalto com a droga e a viatura passou por cima de mim. Por isso fiquei ferido na cabeça, na orelha, joelho e braço. Os policiais militares me abordaram e recolheram a droga. LUIS fugiu com o carro. Não sei se no carro tinha mais alguma coisa. Na fuga, LUIS ligou para a namorada dizendo que tinha "moiado" e mandou ela dar fim no que tivesse na casa deles. Fui levado para a minha casa, pois disse aos policiais que tinha mais maconha lá, que destinava-se ao meu consumo. Fui levado para a Santa Casa e medicado. Depois, fui trazido para a Delegacia de Polícia. Na porta da Delegacia apresentei aos policiais R\$54,00 em dinheiro que refere-se a venda de chinêlos que minha mãe fez para a LUCIANA dona de uma mercearia. Não sei quanto iria receber pela transação, pois não deu tempo de conversar com o LUIS. Sobre LUIS HENRIQUE esclareço que ele mora no bairro Nova Conceição, numa casa de portão de madeira parecida com porteira, com lixeira de madeira. Para chegar na casa de LUIS passa pela frente da minha casa, desce a primeira rua à direita por um quarteirão e meio. A casa de LUIS fica do lado esquerdo no meio do segundo quarteirão. A mãe de LUIS chama IRENE. Ela trabalha no posto de gasolina, pra frente do pedágio. Essa foi a primeira vez que me envolvi com o tráfico de drogas. Sou apenas usuário. Trabalho como trabalhador herbicida na Usina Moreno" (fl. 04).

Quanto à confissão perante a Autoridade Policial, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. Ação ajuizada para reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do defensor, rescisão da condenação no mérito e mitigação das penas impostas. 1) Nulidade. Inocorrência. Prova documental da intimação prévia. Verificação em certidão dos autos. Nulidade afastada. 2) Manifesta contrariedade das provas. Inocorrência. Condenação apoiada nas provas orais. Retratação da petiçãoária tisonada pela mendacidade. Valor da confissão extrajudicial. Impossibilidade de conversão da revisão como terceira instância. Condenação originária mantida. 3) Penas. Dosimetria. Mitigação. Descabimento. Princípio da livre persuasão racional. Discricionariedade motivada. Fundamentação adequada. Elevação da pena-base acima do mínimo. Conformidade com os critérios legais. Improcedente. (TJSP; Revisão Criminal 0053976-97.2015.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017).

O acusado Luís, na fase extrajudicial, disse que: "no dia dos fatos saiu de sua residência a tarde com seu veículo VW/Voyage, cor verde, para abastece-lo, e acabou encontrando o seu amigo Paulo em uma pracinha o qual quando lhe avistou pediu uma carona até a rodoviária da cidade, sendo que Paulo entrou no carro portando uma sacola branca, a qual não sabia o que tinha dentro, sendo que ambos estavam no carro e quando trafegavam sentido a rodoviária, passaram por uma viatura do BAEP,

sendo que a tal viatura passou a segui-los, ocasião em que Paulo ficou assustado e pediu que acelerasse o veículo, na ocasião o interrogando também ficou assustado e acelerou o veículo em sentido a rodoviária, foi quando Paulo lhe disse que pularia do carro, e quando chegou em um cruzamento onde o interrogado afirma que freou o carro para virar a esquina, foi quando Paulo abriu a porta do passageiro e pulou do veículo ainda em movimento, e após fechar a porta de carro continuou fugindo com o veículo, e não foi mais seguido pela viatura, acreditando que eles pararam para deter o Paulo. Que o interrogado afirma que depois de algum tempo soube que apreenderam drogas na posse de Paulo, mas que não sabia de sua existência e que não lhe pertenciam" (fls. 204/205)

Em juízo, os réus negaram a prática dos delitos. No entanto, a negativa é inverossímil e está isolada nos autos, não podendo prosperar. Aliás, a versão do acusado Paulo, em juízo, contraria o seu próprio depoimento prestado perante a Autoridade Policial.

Com efeito, quanto ao delito de tráfico, além da confissão extrajudicial do réu Paulo, há a palavra firme e coerente dos policiais militares. Em juízo, sob o crivo do contraditório e com o compromisso de dizer a verdade, os agentes públicos confirmaram os depoimentos prestados ao Delegado de Polícia, corroborando todos os termos narrados na denúncia.

Nesse ponto, é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada" (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção "jûris tantum" de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagemas para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos". (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 - São Paulo - 4º Câmara de Direito Criminal - Relator

Paulo Rossi - registrada em 21/07/2010).

PORTE ILEGAL DE ARMA - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito em relação a ambos os réus - Validade da palavra dos policiais - Condenação mantida - Pena e regime bem impostos - Descabimento de concessão de qualquer benesse a Alexsandro - Recursos desprovidos (voto nº 29642). (Apelação 0000968-48.2015.8.26.0408. Relator (a): Newton Neves. Comarca: Ourinhos. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 19/07/2016. Data de registro: 20/07/2016).

Os elementos informativos produzidos durante o inquérito policial, aliados às provas da fase processual, demonstram que os fatos ocorreram da seguinte forma: o réu Paulo tomou conhecimento que terceira pessoa teria interesse em comprar considerável quantidade de substâncias entorpecentes. Assim, Paulo atuou como intermediador, negociando a droga entre o comprador e o acusado Luís, este último o proprietário dos entorpecentes. Importante consignar que, embora Paulo tenha negado a propriedade da droga e tentado minimizar/excluir a sua responsabilidade penal, informou que repassou o contato do comprador a Luís e que compareceu ao local onde a droga seria vendida.

Posteriormente, juntos, os acusados compareceram ao local combinado, para entrega dos entorpecentes ao comprador. Pela negociação, o acusado Paulo ganharia R\$ 200,00, por cada 1kg de entorpecente vendido. No entanto, os policiais militares notaram atitudes suspeitas e iniciaram um acompanhamento do veículo em que os acusados estavam. Nesse momento, o condutor (Luís) fugiu, desrespeitando regras de trânsito, enquanto Paulo pulou do carro com os entorpecentes, em uma tentativa de se livrar das drogas. Na abordagem, os policiais declararam que Paulo confirmou que intermediou a venda dos entorpecentes, indicando, inclusive, detalhes da transação, como o valor que receberia em pagamento.

Assim, verifica-se que Paulo, usuário confesso, foi além e, nessa data, efetivamente praticou o tráfico de entorpecentes, colaborando efetivamente com a venda de drogas. A alegação de que estava no local da negociação por mera coincidência é totalmente inverossímil, sobretudo porque o próprio acusado confirmou ser o intermediador da negociação.

Por sua vez, a versão apresentada por Luís também não convence. Em juízo, Luís afirmou que não percebeu a presença dos policiais, nem que estava sendo acompanhado pela polícia. Declarou que não empreendeu fuga em alta velocidade, mas dirigiu normalmente, e que viu Paulo pular do veículo, mas não teve interesse em esclarecer o que estava acontecendo. Ora, tal depoimento carece de qualquer elemento probatório e desafia a lógica. Ficou claro, pelos depoimentos dos agentes públicos, que a droga lhe pertencia e que os réus, agindo em conjunto, negociavam o entorpecente apreendido. Aliás, digno de nota que, pouco tempo depois desses fatos, Luís foi preso em flagrante delito pela prática do delito do artigo 33, da Lei 11.343/06. Soma-se a isso que Luís é reincidente específico e, segundo testemunhas ouvidas em juízo, conhecido por seu envolvimento no comércio ilícito.

Também ficou claro que não há qualquer indicio de parcialidade no depoimento dos policiais, uma vez que nenhum dos acusados indicou problemas pessoais com os agentes públicos e, portanto, não souberam apresentar motivo apto a afastar a credibilidade dos depoimentos. Ainda, a versão dos policiais é amparada pela confissão extrajudicial de Paulo, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga mencionada. No mais, as testemunhas de defesa nada trouxeram para afastar a prática do delito pelos acusados, limitando-se a atestar a boa conduta pretérita dos réus. Cumpre salientar que é irrelevante estar provada a existência de trabalho lícito, visto que a mercancia da droga pode coexistir com ele.

Observo que, para a caracterização do tráfico, não se analisa apenas a quantidade da droga, mas também as circunstâncias da apreensão. Com efeito, a análise do crime de tráfico (artigo 33, caput, Lei 11.343/06) exige a avaliação de todas as circunstâncias do caso concreto. In casu, as circunstâncias da apreensão da droga, bem como o teor da prova oral produzida, demonstram que os dois acusados

transportavam a droga, com plena consciência e agindo de forma dolosa. Isto porque, em fiscalização rotineira, os policiais lograram encontrar 11 tijolos e 09 porções de maconha, pesando 9,57 kg no total. A quantidade de droga apreendida é muito expressiva, especialmente em pequenas cidades, como em José Bonifácio. Cite-se, aqui, lição de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, segundo o qual “em sede de tráfico de substância entorpecente, constitui prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. “Prova Penal”, ed., RT, 2004, item 5, pág. 96). A Jurisprudência dos Tribunais é clara no sentido de elencar alguns, dentre os vários elementos de convicção a evidenciar a condição de traficante. Confira-se:

“Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

“Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercância se destina o tóxico encontrado” (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478).

“Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT”729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (artigo 33, Lei 11343/06), o que, neste caso, constitui o transporte dos entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse pelo agente, para fim de entrega a terceiro, sendo, portanto, desnecessário que seja flagrado vendendo a droga.

Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de, eventualmente, ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado, como mencionado pelo próprio acusado.

Outrossim, a alegação de usuário ou de “viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJESP 101/498).

Portanto, o manancial probatório é coeso em demonstrar que os réus, juntos, promoverem o transporte das substâncias entorpecentes.

Por outro lado, melhor sorte não assiste ao delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06. Quanto ao crime de associação, cuja finalidade específica dos agentes é o cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/06, o delito reclama uma associação dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de agentes.

No caso em pauta, não há provas seguras de que os agentes se reuniam, em caráter de estabilidade e permanência, de forma reiterada, para o cometimento do tráfico. A eventual reunião de agentes caracteriza tão só o concurso de agentes, não havendo falar, dessa união, como tipo penal autônomo. Neste sentido:

Apelação. Tráfico de drogas e associação. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Falta de provas verificada apenas em relação ao delito de associação para o tráfico. Acusado abordado juntamente com uma adolescente, em conhecido ponto de venda de drogas. Entorpecentes apreendidos com a adolescente e todo o dinheiro apreendido em poder do apelante. Expediente comum, empregado por traficantes, buscando atribuir integral responsabilidade ao inimputável. Circunstâncias concretas que colocam em descrédito a versão defensiva. Mantida a condenação por tráfico. Art. 35 da Lei 11.343/06. Necessária distinção entre concurso de agentes e associação. Enquanto o primeiro se mostra ocasional e temporário, o segundo exige estabilidade e permanência. Fatos apurados que não demonstram o vínculo associativo duradouro. Existência de vínculo efêmero que não basta para a caracterização do delito de associação para o tráfico. Absolvição. Penas. Redução. Necessidade. Incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º. Viabilidade. 25 gramas de cocaína e 0,6 grama de maconha. Redução em 2/3. Regime. STF. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. Avaliação do caso concreto. Pequena quantidade que autoriza o regime aberto. Penas alternativas. Resolução 5/12 do Senado Federal. Suficiência das penas restritivas. Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Apelos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 0001550-50.2018.8.26.0535; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 08/09/2019).

No mesmo sentido, in verbis: “a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa” (STJ - HC: 270837 SP 2013/0159054-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação: DJe 30/03/2015).

Note-se: a reunião de pessoas para a prática do crime de tráfico de drogas, por si só, não é suficiente para a condenação pretendida. Há necessidade inequívoca da estabilidade e permanência. E, in casu, os elementos são suficientes para confirmar tão somente o concurso de agentes nos fatos ora apurados.

As provas dos autos não são suficientes para a conclusão, principalmente, da permanência da suposta associação, de modo que a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo à individualização e dosimetria das penas.

Verifico que o réu Paulo Cesar é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 343/344). O acusado Luís Henrique é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, pois possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, anterior à data dos fatos (fls. 345/347). Reconheço, em favor de Paulo, a atenuante da confissão espontânea (confissão durante o inquérito policial, utilizada para fundamentar a condenação).

PAULO CÉSAR RODRIGUES JÚNIOR

Artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado não é portador de maus antecedentes. A elevada quantidade da droga (11 tijolos e 09 porções de maconha, pesando 9,57 kg no total) deve ser considerada na fixação da pena base, nos termos do artigo 42, Lei 11343/06. Sobre o tema já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Em se tratando dos crimes previstos na Lei de Drogas, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06” (STJ, AgRg no HC 244370/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 19-12-2014, grifei).

As demais circunstâncias do artigo 59, CP são comuns aos delitos dessa natureza. Por essa razão, considerando a quantidade de drogas transportadas, aumento a pena-

base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes. Fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento da pena. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Ressalto que, embora não seja este o entendimento usual desta Magistrada, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição de pena ocorre de maneira excepcional, sobretudo em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos.

No curso da instrução processual, não ficou comprovado que o réu se dedicava habitualmente às atividades criminosas, nem que integrasse organização criminosa. É certo que não foram juntadas, aos autos, quaisquer denúncias formalizadas em desfavor do réu Paulo, bem como os policiais não indicaram ser o réu conhecido dos meios policiais por denúncias quanto à comercialização ilícita. Também não foram localizados petrechos de comercialização ilícita (balança de precisão, embalagens etc), dinheiro ou anotações de tráfico em sua residência. Além disso, as provas produzidas demonstraram que o réu Paulo não era proprietário das drogas, tendo agido como intermediador da negociação. Em caso similar:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial que visa o afastamento do tráfico privilegiado, a fixação do regime prisional fechado e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais civis uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Quantidade da droga apreendida que não se mostrou excessiva. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Afastamento da circunstância agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Estado de emergência sanitária que não facilitou a execução da conduta delituosa. Atenuante da menoridade relativa. Súmula n. 231 do STJ. Ausência de comprovação do exercício de atividade laboral lícita, ainda que informal, que não se mostra capaz de afastar a figura do tráfico privilegiado. Registro de atos infracionais que não podem ser utilizados para afirmar a dedicação do acusado à prática de atos ilícitos e, tampouco deturpar sua personalidade e condutado social. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Manutenção da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. Manutenção do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 3. Recurso ministerial conhecido e improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501152-52.2020.8.26.0537; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Destarte, considerados todos os elementos apontados- de um lado, primariedade, ausência de antecedentes criminais, ausência de provas de dedicação à atividade criminosa ou de integrar organização criminosa; de outro lado, a considerável quantidade de drogas apreendida (11 tijolos e 09 porções de maconha, pesando 9,57 kg)- entendo que é possível a aplicação da causa de diminuição da pena em 1/5, fixando-se a pena definitiva em 04 anos de reclusão e 400 dias-multa. Esse, aliás, é o entendimento que vem sendo sufragado no Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. (...) (HC

124.870/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 10/08/2009);

(...) Se o legislador da Lei 11.343/06 não forneceu especificamente os requisitos para fixação do quantum da diminuição prevista no seu artigo 33, § 4º, impõe-se como critério a observância da análise das circunstâncias judiciais, não só as constantes do artigo 59 do CPB, como as demais mencionadas na Lei Antidrogas, e amplamente utilizadas como referencial quando se trata de fixação das penas previstas. (...) (HC 120.832/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 03/08/2009).

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), devidamente atualizado, nos termos do artigo 49, § 1º 2º, CP e artigo 43, Lei 11343/06.

O regime inicial para o cumprimento da pena de prisão é o semiaberto. O crime reveste-se de gravidade em concreto, sobretudo diante da localização de drogas na residência do réu e da elevada